

RECURSO CÍVEL Nº 5067604-78.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: MARCUS GOMES DA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

TRIBUTÁRIO - HORA REPOUSO ALIMENTAÇÃO - HRA - NATUREZA REMUNERATÓRIA À LUZ DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ - EQUIPARAÇÃO A HORA EXTRA E IHT - SUMULA 463 E TEMA 167 AMBOS DO STJ - REFORMA TRABALHISTA - ALTERAÇÃO LEGISLATIVA DA CLT A PARTIR DE 2017 - ADOÇÃO EXPRESSA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA PARA A VERBA - REPERCUSSÃO SOBRE O DIREITO TRIBUTÁRIO - FORMA E RAZÃO DE PAGAMENTO QUE SE MANTÉM IGUAL AO PERÍODO ANTERIOR A 2017 - COERÊNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ - RESSALVA DE ENTENDIMENTO PESSOAL DESTA JULGADORA NO SENTIDO DE QUE A DENOMINAÇÃO DA VERBA NÃO TEM O CONDÃO DE ALTERAR SUA NATUREZA - PACIFICAÇÃO DO TEMA PELA TRU DESTA 2ª REGIÃO NO SENTIDO DE QUE NÃO DEVE HAVER A INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A VERBA DENOMINADA “ADICIONAL DE HORA DE REPOUSO E ALIMENTAÇÃO” (AHRA) OU “HORA REPOUSO ALIMENTAÇÃO” (HRA), PREVISTA NO ART. 3º, II, DA LEI 5.811/1972, ANTE A SUA NATUREZA INDENIZATÓRIA (ART. 71, § 4º, DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO; § 4º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467/2017) - NATUREZA INDENIZATÓRIA - RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do autor, para REFORMAR a sentença, condenando a ré a excluir a verba Hora-Repouso-Alimentação (HRA) da base de cálculo do imposto de renda, bem como a restituir os valores indevidamente descontados a tal título, a partir da entrada em vigor da lei nº 13.467/17, observada a prescrição quinquenal. O valor deve ser corrigido unicamente pela taxa SELIC, que engloba juros moratórios e correção monetária. Sem condenação do recorrente em custas e honorários advocatícios, eis que vencedor. A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se as partes. Publique-se. Com o trânsito em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 13 de novembro de 2024.

5067604-78.2024.4.02.5101

510014719324 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5067604-78.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: MARCUS GOMES DA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RELATÓRIO

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso interposto.

Trata-se de demanda na qual a parte autora pretende a exclusão dos valores pagos a título de **hora repouso alimentação (HRA)** e **Indenização por Repouso Semanal Remunerado** não gozado da base de cálculo do imposto de renda e a condenação da ré na restituição dos valores indevidamente cobrados.

O juízo de origem julgou **improcedente ambos os pedidos.**

Em sede recursal, a parte autora recorre tão somente quanto à rubrica HRA e sustenta a natureza indenizatória da referida verba e, portanto, a não incidência do imposto de renda.

Eis o pedido recursal (evento 49, RECLNO1): *"I - O conhecimento e provimento do presente recurso inominado para reformar a sentença nos termos declinados na corrente peça recursal, julgando procedente os pedidos da pretensão autoral indicados nos subitens "A", do item II, do capítulo VI, "Dos Pedidos", qual seja, "declarar a inexistência de relação jurídico-tributária quanto ao imposto de renda de pessoa física incidente sobre as rubricas: A) Adicional de intervalos HRA (horas repouso)."*

Nos contracheques apresentados (evento 1, CHEQ7), consta o recebimento de Adicional HRA.

É o relatório. Decido.

VOTO

A rubrica reclamada foi prevista na Lei 5.811/72 para atividades relacionadas a exploração de petróleo e congêneres e desenvolvidas sob regime de revezamento de oito horas:

Art. 2º Sempre que for imprescindível à continuidade operacional, o empregado será mantido em seu posto de trabalho em regime de revezamento.

§ 1º O regime de revezamento em turno de 8 (oito) horas será adotado nas atividades previstas no art. 1º, ficando a utilização do turno de 12 (doze) horas restrita às seguintes situações especiais:

a) atividades de exploração, perfuração, produção e transferência de petróleo do mar;

b) atividades de exploração, perfuração e produção de petróleo em áreas terrestres distantes ou de difícil acesso.

*§ 2º Para garantir a normalidade das operações ou para atender a imperativos de segurança industrial, **poderá ser exigida, mediante o pagamento previsto no item II do art. 3º, a disponibilidade do empregado no local de trabalho ou nas suas proximidades, durante o intervalo destinado a repouso e alimentação.***

Art. 3º Durante o período em que o empregado permanecer no regime de revezamento em turno de 8 (oito) horas, ser-lhe-ão assegurados os seguintes direitos:

*I - Pagamento do adicional de trabalho noturno na forma do **art. 73 da Consolidação das Leis do Trabalho;***

*II - **Pagamento em dobro da hora de repouso e alimentação suprimida nos termos do § 2º do art. 2º;***

III - Alimentação gratuita, no posto de trabalho, durante o turno em que estiver em serviço;

IV - Transporte gratuito para o local de trabalho;

V - Direito a um repouso de 24 (vinte e quatro) horas consecutivas para cada 3 (três) turnos trabalhados.

Parágrafo único. Para os empregados que já venham percebendo habitualmente da empresa pagamento à conta de horas de repouso e alimentação ou de trabalho noturno, os respectivos valores serão compensados nos direitos a que se referem os itens I e II deste artigo.

Portanto, a chamada HRA somente é paga em dobro quando há **disponibilidade do empregado no local de trabalho, durante o intervalo destinado a repouso e alimentação, justamente para que possa trabalhar.** Este direito, inclusive, também pode ser extraído da CLT, art 71, § 4o.

A discussão que se estabelece é se este pagamento em dobro teria natureza indenizatória ou não. O STJ possui um julgado de 2017 (REsp 1328326 / BA) que entende que o pagamento a maior tem por escopo recompor direito legítimo do empregado, assumindo caráter de compensação.

A interpretação prevalente, porém, é no sentido de que durante este período o empregado fica, efetivamente, a disposição da empresa para trabalhar de modo que recebe por tal hora tal como se fosse trabalhada, caracterizando, portanto, remuneração. Neste sentido, a verba seria equiparada a hora extra ou mesmo IHT pagas pela Petrobras, aplicando-se assim, a sumula 463 do STJ e tema 167 do mesmo tribunal (vide, neste sentido, EDcl no REsp 1157849 / RS julgado em 2011):

TEMA 167/09: Incide imposto de renda sobre a verba intitulada 'Indenização por Horas Trabalhadas' - IHT, paga aos funcionários da Petrobrás, malgrado fundada em acordo coletivo.

SUMULA 463/10: Incide imposto de renda sobre os valores percebidos a título de indenização por horas extraordinárias trabalhadas, ainda que decorrentes de acordo coletivo.

E examinando a questão à luz da jurisprudência mais recente do E. STJ, percebe-se que o aparente conflito de entendimentos entre a 1ª e a 2ª Turmas do STJ foi pacificado, prevalecendo a natureza remuneratória da verba à luz da redação original do art. 71, § 4º da CLT que seria a base do direito explicitado na legislação extravagante:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. HORA REPOUSO ALIMENTAÇÃO (HRA). INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC.

2. No julgamento dos Embargos de Divergência em REsp 1.619.117/BA, a **Seção de Direito Público do STJ concluiu que, até a entrada em vigor da Lei 13.467/2017, a verba denominada Hora Repouso Alimentação (HRA) possui natureza remuneratória, submetendo-se à incidência de contribuição previdenciária.**

3. Recurso Especial parcialmente provido.

(REsp 1861922/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 21/08/2020)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HORA REPOUSO ALIMENTAÇÃO (HRA). NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS

1. Cinge-se a controvérsia à possibilidade de incidência da contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos a título de Hora Repouso Alimentação - HRA, prevista nos arts. 3º, II, da Lei 5.811/1972 e 71, § 4º, da CLT.

2. O acórdão embargado consignou que tal verba "[...] reveste natureza jurídica autenticamente indenizatória, pois seu escopo é recompor direito legítimo do empregado suprimido em virtude das vicissitudes da atividade laboral, assumindo perfil de genuína compensação, de verdadeira contrapartida a que o empregador está obrigado, por lei, a disponibilizar ao obreiro, em virtude da não fruição do direito ao intervalo para refeição e repouso que lhe é garantido, imprescindível ao restabelecimento do seu vigor físico e mental".

3. Partindo da premissa de que a Hora Repouso Alimentação - HRA possui natureza indenizatória, concluiu que sobre ela não deve incidir a contribuição previdenciária patronal (art. 22, I, da Lei 8.212/1991).

4. O julgado apontado como paradigma, por sua vez, assentou: "**a 'Hora Repouso Alimentação - HRA' [...] é paga como única e direta retribuição pela hora em que o empregado fica à disposição do empregador**", configurando, assim, "**retribuição pelo trabalho ou pelo tempo à disposição da empresa e se submete à contribuição previdenciária, nos termos do art. 28 da Lei 8.212/1991**".

5. É patente a similitude fática entre os acórdãos confrontados, bem como a divergência entre as soluções jurídicas adotadas em cada caso.

PRECEDENTES DA PRIMEIRA E DA SEGUNDA TURMA DO STJ

6. A Primeira Turma reconheceu que a HRA reveste natureza jurídica autenticamente indenizatória em mais um precedente: REsp 1.328.326/BA, Rel. Min. Gurgel de Faria, Rel. p./acórdão Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 26.5.2017.

7. Na Segunda Turma, prevalece a compreensão de que a Hora Repouso Alimentação - HRA possui natureza remuneratória, devendo incidir sobre ela a contribuição previdenciária patronal. Precedentes: AgInt no REsp 1.727.114/BA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.5.2019; AgInt no AREsp 1.122.223/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.8.2019; AgRg no REsp 1.449.331/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13.5.2016; REsp 1.144.750/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25.5.2011; EDcl no REsp 1.157.849/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 26.5.2011.

NATUREZA JURÍDICA DA HORA REPOUSO ALIMENTAÇÃO

8. A Hora Repouso Alimentação - HRA constitui verba paga ao trabalhador pela disponibilidade do empregado no local de trabalho, ou nas suas proximidades, durante o intervalo destinado a repouso e alimentação, conforme o art. 2º, § 2º, da Lei 5.811/1972.

9. O pagamento por essa "disponibilidade do empregado" é feito nos termos dos arts. 3º, II, da Lei 5.811/1972 e 71, § 4º, da CLT.

10. A Hora Repouso Alimentação - HRA é paga como única e direta retribuição pela hora em que o empregado fica à disposição do empregador. Ou seja, o trabalhador recebe salário normal pelas oito horas regulares e HRA pela 9ª (nona) hora, em que ficou à disposição da empresa.

11. Inexiste simplesmente supressão da hora de descanso, hipótese em que o empregado ficaria 8 horas contínuas à disposição da empresa e receberia por 9 horas (haveria "indenização" pela hora de descanso suprimida).

12. O empregado fica efetivamente 9 (nove) horas contínuas trabalhando ou à disposição da empresa e recebe exatamente por esse período, embora uma dessas horas seja paga em dobro, a título de HRA. Trata-se de situação análoga à hora extra: remuneração pelo tempo efetivamente trabalhado ou à disposição do empregador e sujeita à contribuição previdenciária.

13. Ao contrário do afirmado no acórdão embargado, a HRA possui nítida natureza remuneratória, submetendo-se à tributação pela contribuição previdenciária patronal, nos termos dos arts. 22, I, e 28 da Lei 8.212/1991.

14. Tratando da incidência da contribuição previdenciária sobre a HRA, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 1.039.689/RS (Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.9.2017), afirmou: "Desse modo, não diverge o Tribunal a quo do entendimento da Corte no sentido da incidência de contribuição previdenciária patronal sobre verbas remuneratórias, conforme ficou deliberado no julgamento do RE nº 565.160/SC (Tema 20 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet). Verifico que, nessa decisão, a Corte se debruçou sobre o alcance da expressão 'folha de salários', contida no art. 195, I, 'a', da Constituição Federal, que é base de cálculo da exação em tela".

15. Em obiter dictum, impende ressaltar que a redação do art. 71, § 4º, da CLT foi alterada pela Lei 13.467/2017: "A não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo, para repouso e alimentação, a empregados urbanos e rurais, implica o pagamento, de natureza indenizatória, apenas do período suprimido, com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho".

16. A compreensão esposada abrange apenas os pagamentos e recolhimentos realizados antes da entrada em vigor da Lei 13.467/2017, uma vez que a nova redação do art. 71, § 4º, da CLT não foi objeto de discussão no presente caso.

CONCLUSÃO

17. Embargos de Divergência providos, para reconhecer a incidência da contribuição previdenciária patronal sobre a Hora Repouso Alimentação - HRA, até a entrada em vigor da Lei 13.467/2017.

(*REsp 1619117/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/11/2019, DJe 08/05/2020*)

A própria decisão deixa claro que a natureza remuneratória da HRA é assegurada até ao advento da Lei nº 13.467/2017, dada a redação original do art 71, § 4 da CLT, que falava em remuneração das horas excedentes as 6 de trabalho ordinário:

Art. 71 - Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda de 6 (seis) horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será, no mínimo, de 1 (uma) hora e, salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, não poderá exceder de 2 (duas) horas.

(...)

*§ 4º - Quando o intervalo para repouso e alimentação, previsto neste artigo, não for concedido pelo empregador, este ficará obrigado a **remunerar** o período correspondente com um acréscimo de no mínimo 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho.*

A Reforma Trabalhista alterou a redação do dispositivo, atribuindo natureza indenizatória ao pagamento feito em dobro pela supressão do intervalo de repouso e alimentação concedido a cada 6 horas de trabalho:

*Art. 71 - Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda de 6 (seis) horas, é obrigatória a concessão de um **intervalo para repouso ou alimentação**, o qual será, no mínimo, **de 1 (uma) hora** e, salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, não poderá exceder de 2 (duas) horas.*

§ 1º - Não excedendo de 6 (seis) horas o trabalho, será, entretanto, obrigatório um intervalo de 15 (quinze) minutos quando a duração ultrapassar 4 (quatro) horas.

§ 2º - Os intervalos de descanso não serão computados na duração do trabalho.

(...)

*§ 4º **A não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo, para repouso e alimentação, a empregados urbanos e rurais, implica o pagamento, de natureza indenizatória, apenas do período suprimido, com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho.*** (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017) (Vigência)

(...)

A questão, portanto, passa a ser o alcance da CLT para fixar a natureza da verba paga ao empregado com repercussão sobre a matéria tributária.

Neste sentido, o CTN fixa, como fato gerador do imposto de renda, a aquisição de disponibilidade econômica fruto do trabalho. Destaca, ainda, que "**a incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção.**":

*Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza **tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:***

I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;

II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.

§ 1º A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

§ 2º Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

Art. 44. A base de cálculo do imposto é o montante, real, arbitrado ou presumido, da renda ou dos proventos tributáveis.

Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo 43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens produtores de renda ou dos proventos tributáveis.

Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe caibam.

O entendimento do STJ que justificou a natureza remuneratória da verba e consequente incidência do imposto de renda antes da reforma trabalhista de 2017 foi a construção de que, o valor pago a maior apenas o era por pressupor a disponibilidade do empregado para trabalhar para o empregador caso este assim exigisse, sendo, portanto, verba fruto de trabalho, tal como qualquer remuneração, e paga a maior por exceder o tempo máximo permitido sem intervalo intrajornadas. Daí porque afastou a similitude da verba com férias indenizadas (onde é feito pagamento por supressão de direito legítimo a descanso) e a equiparou à hora extraordinária, sobre a qual não se discute a incidência de imposto de renda (sumula 463 do STJ):

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. EFEITO INFRINGENTE AOS ACLARATÓRIOS. CONHECIMENTO DO MÉRITO RECURSAL. PAGAMENTO POR HORA A TRABALHADOR QUE FICA À DISPOSIÇÃO DA EMPRESA, DURANTE O DESCANSO DIÁRIO. SITUAÇÃO ANÁLOGA À DA INDENIZAÇÃO POR HORA TRABALHADA - IHT. NATUREZA REMUNERATÓRIA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. INCIDÊNCIA.

(...)

7. No mérito, discute-se a incidência da contribuição previdenciária sobre os valores pagos por indústria química e petroquímica pela disponibilidade do empregado no local de trabalho ou nas suas proximidades durante o intervalo destinado a repouso e alimentação, conforme o art. 2º, § 2º, da Lei 5.811/1972, conhecida por "Hora Repouso Alimentação - HRA".

8. O TRF acolheu o pleito da contribuinte e afastou a tributação, aplicando, por analogia, o entendimento referente às férias indenizadas.

9. Ocorre que não há similitude com as férias acima citadas, em que inexistente relação direta entre o pagamento feito e o trabalho realizado pelo empregado.

10. Nas férias indenizadas (totalmente diferente do caso dos autos), o funcionário recebe duas vezes: 1 salário normal pelo mês que trabalhou (quando deveria estar de férias) + 1 "salário indenização" pelas férias que perdeu. A tributação incide sobre o primeiro salário, normalmente (porque é retribuição pelo trabalho), mas não sobre o segundo "salário", cuja natureza é indenizatória, exatamente porque não é retribuição por trabalho ou tempo à disposição da empresa.

11. A "Hora Repouso Alimentação - HRA", diversamente, é paga como única e direta retribuição pela hora em que o empregado fica à disposição do empregador.

12. Não há simplesmente supressão da hora de descanso, hipótese em que o trabalhador ficaria disponível 8 horas contínuas para a empresa e receberia por 9 horas (haveria uma "indenização" pela hora suprimida). O empregado fica efetivamente 9 horas ininterruptas trabalhando ou disponível para a empresa e recebe exatamente por este período, embora uma destas horas seja paga em dobro, a título de HRA.

13. A analogia possível é com a hora extra, a remuneração pelo tempo efetivamente trabalhado ou à disposição do empregador e sujeita à contribuição previdenciária.

14. É precisamente essa a orientação fixada pela Primeira Seção, em recurso repetitivo, ao julgar o caso da "Indenização por Horas Trabalhadas - IHT" paga pela Petrobras e decidir pela natureza remuneratória da verba para fins de aplicação do Imposto de Renda.

15. A "Hora Repouso Alimentação - HRA" é, portanto, retribuição pelo trabalho ou pelo tempo à disposição da empresa e se submete à contribuição previdenciária, nos termos do art. 28 da Lei 8.212/1991.

16. Em seus memoriais, a empresa insiste na indevida analogia com as férias e licença-prêmio indenizadas, que, diferentemente da HRA e do IHT, não são remuneração por trabalho realizado, nem por tempo à disposição do empregador.

17. A indenização por férias não gozadas é excepcional, decorrente do descumprimento da norma que garante ao trabalhador o descanso anual. A HRA é remuneração ordinária, prevista em lei, que não tem origem no descumprimento de norma legal. Inexiste semelhança que autorize a interpretação analógica pretendida pela empresa.

18. Embargos de Declaração acolhidos com efeito infringente para dar provimento ao Recurso Especial.

(EDcl no REsp 1157849/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2011, DJe 26/05/2011)

Percebe-se, portanto, que a nova redação dada a CLT não tem o condão de alterar o estado de fato atinente a natureza da verba pela só menção a indenização posto que a **forma e razão pela qual ela era paga continua a subsistir independente da redação adotada pela CLT.**

Conforme afirma o art. 109 do CTN, os princípios gerais de direito privado devem ser utilizados para pesquisa da definição, do conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas não para definição dos respectivos efeitos tributários. Nessa linha, o conceito de renda compreende o produto do trabalho, de forma que se a verba serve de contraprestação aos serviços prestados, ela configura-se como renda e, pois, tributável pelo IR.

Em seguida, o art. 110 do CTN dispõe que a **lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos**, conceitos e formas de direito privado utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para **definir ou limitar competências tributárias.**

Seguindo essa mesma ordem de ideias, em caso semelhante, o STJ decidiu que o simples fato de a lei denominar a verba como "indenizatória" não afasta, por si só, a incidência do imposto de renda. Isso porque não é o nome atribuído à verba que definirá a incidência ou não do imposto. Verbas que constituam acréscimo patrimonial, ainda que pagas sob a rubrica de "indenização", serão tributadas. Aplica-se, ao caso, o art. 110 do CTN, acima citado.

RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA SOBRE VERBA PAGA COMO CONTRAPRESTAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS.

1. A Lei nº 1.575/2011 do Estado do Amapá, apesar de considerar a verba correspondente a plantões médicos como indenizatória, não transmuta a natureza jurídica desta verba para fins de imposto de renda. Precedente: RMS n. 50.738/AP, Primeira Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 10/05/2016, DJe03/06/2016.

2. Isto porque, como bem o ressaltou a Corte de Origem (e-STJ fls. 72): "apesar de a redação do art. 5º da Lei Estadual n. 1.575/2011 prever que a remuneração dos plantões médicos possui natureza indenizatória, não há como fechar os olhos à realidade, posto que tais pagamentos são habituais, comutativos e de caráter eminentemente retributivo do serviço prestado mês a mês e não se prestam a ressarcir qualquer gasto ou despesa extraordinária realizada pelo servidor [...]".

3. A verba assim instituída se assemelha àquela paga por horas extras aos demais trabalhadores da iniciativa privada ou servidores públicos, constituindo evidentemente remuneração, pois corresponde à paga pelo serviço prestado fora dos horários habituais. Para estes casos (hora extra) é pacífica a jurisprudência deste STJ no sentido da incidência do imposto de renda, a saber: EREsp. Nº 695.499 - RJ, Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 9.5.2007; EREsp 670514 / RN, Primeira Seção, Rel. Min. José Delgado, DJ de 16.06.2008; EREsp. n. 515.148/RS, Primeira Seção, Relator Ministro LUIZ FUX, Data do julgamento 08/02/2006.

4. Recurso ordinário não provido.

(RMS 52.051/AP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 24/05/2021)

Assim, **em que pese não concordar com o entendimento prevalente do STJ**, buscando resguardar coerência com a *ratio* de seus julgados, aos quais está este órgão vinculado, tem-se que a natureza remuneratória da verba se mantém para fins de direito tributário, incidindo, outrossim, o imposto de renda vergastado.

Todavia, diante da pacificação do presente tema pela Turma Regional de Uniformização desta 2ª Região nos precedentes de números 5000699-90.2021.4.02.5006, 5018745-79.2020.4.02.5001 e 5022436-04.2020.4.02.5001, curvo-me ao entendimento da maioria no sentido de que **não deve haver a incidência do imposto de renda sobre a verba**

denominada “Adicional de Hora de Repouso e Alimentação” (AHRA) ou “Hora Repouso Alimentação” (HRA), prevista no art. 3º, II, da Lei 5.811/1972, ante a sua natureza indenizatória (art. 71, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho; § 4º com redação dada pela Lei 13.467/2017).

Esta mesma posição foi adotada pela Turma Nacional de Uniformização no âmbito do Tema 306, no qual foi fixada a seguinte tese: *“Com o advento da Lei nº 13.467, de 13/07/2017, que deu nova redação ao § 4º do art. 71 da CLT e estabeleceu expressamente a natureza indenizatória do pagamento operado pela supressão do intervalo intrajornada, habitualmente conhecido como Adicional Hora de Repouso e Alimentação (AHRA), em conformidade com a proteção constitucional à saúde do trabalhador (arts. 7º, XXII, 194, caput, 197 e 200, II, bem como art. 5º, § 2º c.c. arts. 4º e 5º da Convenção 155 da OIT, incorporada ao direito interno pelo Decreto n. 1.254/94, hoje consolidada no Decreto n. 10.088/2019 e o art. 7º, do Pacto Internacional Relativo aos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 1966, incorporado ao direito interno pelo Decreto n. 591/92), não incide imposto de renda sobre a verba paga a tal título.”* (PEDILEF 0520381-15.2020.4.05.8400/RN; Relator: Juiz Federal Francisco de Assis Basílio de Moraes - Para acórdão: Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves; publicado em 17/03/2024).

Ante o exposto, voto por **CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO** ao recurso do autor, para REFORMAR a sentença, condenando a ré a excluir a verba Hora-Repouso-Alimentação (HRA) da base de cálculo do imposto de renda, bem como a restituir os valores indevidamente descontados a tal título, a partir da entrada em vigor da lei nº 13.467/17, observada a prescrição quinquenal. O valor deve ser corrigido unicamente pela taxa SELIC, que engloba juros moratórios e correção monetária. Sem condenação do recorrente em custas e honorários advocatícios, eis que vencedor. **A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).** Intimem-se as partes. Publique-se. Com o trânsito em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto.